

1501283-75.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... no começo desse ano pelo delito e tráfico e aguarda julgamento. Os elementos trazidos, inclusive a confissão na delegacia, demonstram que o réu já havia saído de casa e fazia do tráfico seu modo de subsistência e para manutenção de seu vício. Postula a fixação da pena no mínimo legal em razão da primariedade do réu. Na segunda fase relembra ser o réu primário e que também é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501283-75.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501283-75.2020.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Wesley Martins Lorena

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Diogo Wesley Martins Lorena foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 9 de dezembro de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Antônio Canineo, próximo ao nº 88, Bairro Areão, nesta cidade e comarca de Taubaté, previamente ajustado e com unidade de propósito com terceiro não identificado, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e trazia consigo para fins de venda e entrega a terceiros consumidores, 27 pinos com cocaína, com massa líquida de 13,8 gramas, substância causadora de dependência física e psíquica.

Segundo apurado pela acusação, o réu vinha habitualmente e deliberadamente praticando o narcotráfico nesta cidade, visando auferir renda para sustentar seu vício e pagamento de suas dívidas, fazendo dessa atividade espúria seu meio de sobrevivência.

Foi então que, na tarde dos fatos, o réu recebeu 39 pinos com cocaína de terceiro não identificado para a comercialização, junto da orientação do preço das drogas, que custavam R\$ 20,00 cada pino. De posse das substâncias entorpecentes, ele se

deslocou até o endereço supramencionado e realizou atos de mercancia ilícita, auferindo dinheiro.

Ocorre que, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina e notaram que ele apresentou comportamento suspeito ao avistar a viatura, resolvendo abordá-lo.

Efetuada revista pessoal, foi encontrada, dentro de sua veste íntima, uma sacola contendo 23 pinos com cocaína e, dentro do bolso de sua bermuda, mais 4 pinos, todos embalados de forma individualizada, prontas para serem vendidas. Além disso, foi apreendida a quantia de R\$ 116,00 em dinheiro, proveniente do tráfico.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida às fls. 101/103.

Citado por edital (fls. 135), o réu não compareceu e não constituiu defensor, motivo pelo qual o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, à fls. 144.

Citado pessoalmente (fls. 156), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 161.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas José Custódio Vieira e Bruna Cristina Santos Fonseca, e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Na delegacia o réu confessou o delito, dizendo que havia recebido 39 pinos e já tinha feito a venda de alguns. Os policiais ouvidos disseram que abordaram o réu na posse de droga e dinheiro, procedendo à prisão em flagrante. Em juízo o réu afirmou que estava desempregado e que havia trocado as drogas por uma bicicleta, para seu uso pessoal. Afirma que a versão apresentada pelo réu não encontra amparo no conjunto probatório. O réu afirmou que foi preso no começo desse ano pelo delito e tráfico e aguarda julgamento. Os elementos trazidos, inclusive a confissão na delegacia, demonstram que o réu já havia saído de casa e fazia do tráfico seu modo de subsistência e para manutenção de seu vício. Postula a fixação da pena no mínimo legal em razão da primariedade do réu. Na segunda fase relembra ser o réu primário e que também é possível a aplicação do redutor, no patamar de $\frac{1}{2}$, diante da quantidade de drogas, sendo o regime inicial o semiaberto.

A Defesa, por sua vez, afirmou que o comércio da droga não foi provado. Alegou que como morador de rua recusou internação e a família estava desesperada. Alegando ser o réu usuário, pediu a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento parcial do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de depoimento (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo pericial (fls. 88/90) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Bruna Cristina Santos Fonseca, em juízo, asseverou que se recorda da ocorrência. Esclareceu que na data dos fatos, estava fazendo patrulhamento pelo bairro do Areão, que é ponto constante de venda de drogas, quando viram o réu sentado embaixo da árvore. Informou que acharam estranho que alguém estivesse sentado nesse horário, naquela área. Alegou que deram mais uma volta com a viatura, e resolveram fazer a abordagem. Asseverou que foi encontrado com o réu drogas e dinheiro. Esclareceu que o réu confessou o crime e justificou dizendo que tinha muitas dívidas e precisava daquele dinheiro. Alegou que foi a primeira vez que viu o réu.

A testemunha José Custódio Vieira, em juízo, asseverou que se recorda da ocorrência. Informou que na data dos fatos, estava em patrulhamento e viram o réu em local suspeito. Esclareceu que resolveram fazer a abordagem e no mesmo momento houve confissão do réu. Asseverou que o réu informou que estava com dívidas e precisava do dinheiro.

O réu Diogo Wesley Martins Lorena, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação. Informou que reconhece a autoria do crime. Alegou que era usuário de drogas, não sabia o que fazer e vendeu sua bicicleta, para comprar as drogas. Esclareceu que as drogas eram para seu uso, pois era dependente químico. Asseverou que usa drogas desde os 18 anos, e que hoje tem 21. Informou que é casado. Asseverou que tem um filho. Alegou que morava na rua e estava desempregado, sobrevivendo de bicos. Informou que tem conhecimento de outros dois processos a que responde. Esclareceu que está preso desde fevereiro, por tráfico de drogas e aguarda julgamento agendado para agosto.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que se somam às provas produzidas sob contraditório judicial, verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo drogas, previsto no núcleo do tipo, assim, configurada a traficância.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que depois de abordar o réu em um local que se destina ao tráfico encontraram com ele pinos dentro de suas vestes e, ainda, em seu bolso.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais, não é razão para descartar o teor depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive

reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Além disso, quando ouvido na delegacia, o réu confessou que no local realizava o tráfico, sendo que o fazia para pagar dívidas e sustentar o vício.

Assim, não há dúvida acerca dos fatos, que demandam a responsabilização do réu.

A alegação defensiva, tanto em autodefesa como em defesa técnica, de que a droga se destinava ao seu uso não encontra guarida nos autos.

Primeiro porque o réu confessou na delegacia que estava no local a traficar.

Ademais, cabe dizer que a retratação posterior não invalida aquela realizada na delegacia de polícia.

Anoto que na oportunidade de seu primeiro interrogatório, os fatos estão vivos na memória e, muitas vezes em razão da surpresa e do curto espaço tempo decorrido entre o fato e a oitiva, a verdade vem à tona, sem que tenha tempo hábil para que o acusado formule teses defensivas, desviadas da sinceridade.

Nesse passo é que entendem os tribunais que a confissão vale por seu próprio teor, e não pelo lugar onde é prestada.

"Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do correu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade"(TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel.Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).

A propósito da questão, em seu interrogatório em juízo o réu afirmou que vendeu uma bicicleta para adquirir as drogas, alterando a versão dos fatos ocorridos, tentando induzir o Juízo em erro, unicamente para tentar desviar-se da responsabilidade que é certa.

Nesse particular, não se afigura crível que alguém que se encontrava em situação de rua, sem atividade que lhe proporcionasse renda, tivesse em seu poder uma bicicleta para vender e amealhar dinheiro para comprar droga como afirmou.

Outrossim, a quantidade de droga encontrada em poder do réu, não demonstra que fosse para seu uso, pois foram 27 tubos com cocaína o que, indubitavelmente, não se mostra compatível com o uso próprio, mormente para alguém que vivia em situação de rua, sem renda, como ressaltado.

Impõe-se anotar a menoridade relativa do réu, uma vez que na época dos fatos contava com 19 anos de idade.

Há de se reconhecer, ainda, que o delito em questão se amolda no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra associação criminosa, o que demanda a redução pelo máximo de 2/3.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nelson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A qualidade da droga (cocaína) e quantidade não pesa em desfavor do réu.

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Em razão das circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão do réu feita na repartição policial, que foi utilizada para fundamentar sua condenação, contudo, não podem levar a pena abaixo do mínimo legal em razão do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica a pena mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, observo a causa de diminuição relativa ao artigo 33, §4.º, da Lei de Drogas, que importa diminuir a pena em 2/3, alçando-a ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Não há causa de aumento,

razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, de se lembrar que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 118. 533/MS), de forma que sendo a condenação inferior a 4 anos, somada à pequena quantidade de entorpecente, entende-se que, nesse caso, o regime imposto deve ser o aberto.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Também, excepcionalmente, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Isso porque a pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência, o réu não é reincidente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Tendo em conta que a pena é maior que um ano, nos termos do artigo 44, §2.º, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo esteve ele em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou, em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.ª ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443)

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que ele permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Diogo Wesley Martins Lorena à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, com início de cumprimento no regime aberto, substituindo a pena

privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA